RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 278.575 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
ADV.(A/S)	: HELEN NASCIMENTO DA SILVA
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

DECISÃO:

Vistos.

Trata-se de **recurso ordinário em habeas corpus**, com pedido de liminar, interposto em favor de **Allan Delon de Carvalho Lacerda**, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 1.051.069/DF, Relator o Ministro **Rogério Schietti** (e-doc. 53).

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, *caput*, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, a defesa impetrou **habeas corpus** perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Interposto agravo regimental, o colegiado do STJ negou provimento ao recurso.

Neste recurso (e-doc. 59), a defesa sustenta, em síntese, a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente em virtude da ausência de fundamentação idônea para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, com base em atos infracionais pretéritos.

Requer, ao final:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

> "a) a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos do v. acórdão recorrido, reconhecer provisoriamente a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e determinar o redimensionamento provisório da pena e do regime prisional, até o julgamento definitivo do recurso;
>
> b) o conhecimento do presente recurso ordinário constitucional em *habeas corpus;*
>
> c) o seu provimento, para reformar o v. acórdão recorrido e conceder a ordem de *habeas corpus,* reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com o consequente redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, determinando-se ao Juízo de origem a expedição do necessário;
>
> d) subsidiariamente, caso superado qualquer óbice ao conhecimento do recurso, seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal."

É o relatório.

Fundamento e decido.

Transcrevo a ementa do aresto recorrido:

> "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Tendo em vista que, no caso, os atos infracionais praticados pelo ora paciente, enquanto ainda adolescente, foram graves; os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais, entendo que não há como se reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".

5. Agravo regimental não provido" (e-doc.53).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

Com efeito, no STJ o Ministro **Rogerio Schietti** no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

> "Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.
>
> Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
>
> A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (**HC n. 437.178/SC,** Rel. Ministro **Ribeiro Dantas**, 5ª T., DJe 11/6/2019).
>
> No caso, as instâncias ordinárias – **dentro do seu livre convencimento motivado** – apontaram **elementos concretos dos autos** a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
>
> Para tanto, salientou o Juiz sentenciante que "Em que pese tecnicamente primário, há de se observar que **o acusado possui três condenações por atos infracionais (Execuções nº 0004837-63.2018.8.07.0013, 0003381- 78.2018.8.07.0013 e 0002029-51.2019.8.07.0013 – duas delas, inclusive, pela prática de ato análogo a roubo majorado),** circunstância que evidencia dedicação do réu a atividades criminosas, a obstar a causa de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006" (fl. 43).

Na mesma linha argumentativa, ressaltou o Tribunal de origem que, "**o sentenciante se baseou no histórico de atos infracionais do apelante para obstar a benesse legal, o que é admitido,** em certos casos, pela jurisprudência, desde que haja fundamentação idônea com base na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade destes com o evento criminoso em apuração" (fl. 26, grifei).

E destacou ainda que, "em consulta à FAP do acusado, apesar de, como visto, ele ser tecnicamente primário, não ostentar maus antecedentes e nem ser reincidente, **sua certidão de passagem na Justiça Juvenil demonstra histórico infracional relevante (ID 63778944). No período compreendido de 2019 a 2021, o acusado respondeu a procedimentos pela prática de atos infracionais análogos a crimes de roubo majorado (duas vezes)**" (fl. 29, grifei).

Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos **EREsp n. 1.916.596/SP** (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra **Laurita Vaz**), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, entendimento intermediário no sentido de que **o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

> **existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.**
>
> Na hipótese dos autos, a) os atos infracionais praticados pelo ora paciente, enquanto ainda adolescente, foram **graves (roubo majorado);** b) os registros infracionais estavam **devidamente documentados** nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi **pequena a distância temporal** entre os atos infracionais e o crime objeto deste recurso (o qual foi perpetrado quando o réu tinha menos de 21 anos de idade), entendo que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, **por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas**".
>
> Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável em sede de habeas corpus**.**
>
> Assim, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não há como se reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".
>
> À vista do exposto, **nego provimento ao agravo regimental.**" (e-doc. 53, p. 3-5).

Na espécie, **verifico a existência de ilegalidade com relação à causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Explico.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin).

No caso, a sentença condenatória, ao negar a concessão do tráfico privilegiado, assim fundamentou (e-doc. 6, p. 8):

> Em que pese tecnicamente primário, há de se observar que o acusado possui três condenações por atos infracionais (Execuções nº 0004837-63.2018.8.07.0013, 0003381-78.2018.8.07.0013 e 0002029-51.2019.8.07.0013 – duas delas, inclusive, pela prática de ato análogo a roubo majorado), circunstância que evidencia dedicação do réu a atividades criminosas, a obstar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesses termos, observa-se que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, **está consubstanciada na conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais**.

Entretanto, a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte sedimentou o entendimento no sentido de não admitir que atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado. A propósito, confiram os seguintes precedentes:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 2. Necessidade de realização de nova dosimetria da pena imposta ao agravante, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus". (HC 228203 AgR, de **minha relatoria**, Relator(a) p/ Acórdão: **ANDRÉ MENDONÇA**, Segunda Turma, DJe de 15/08/2023)

"AGRAVO INTERNO EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido. (HC 226564 AgR, Rel. Min. **NUNES MARQUES**, Segunda Turma, DJe de 31/08/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC 193.816/AgR/SP, Rel. Min. **Cármen Lúcia**, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS* INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado. II - A quantidade de droga apreendida, fundamento agora invocado pelo agravante, além de constituir indevido incremento de fundamentação não admitido pela jurisprudência do STF, porque não foi utilizado pelo Magistrado sentenciante para esse fim, também não impede a incidência da minorante em questão. Precedentes da Segunda Turma do STF. III - Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento". (RHC 210056 AgR, Rel. Min. **RICARDO LEWANDOWSKI**, Segunda Turma, Dje de 15/03/2022)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50

Desse modo, o registro pretérito de ato infracional não constitui fundamento idôneo para, **isoladamente**, afastar a causa de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, **dou provimento parcial** ao presente recurso ordinário em *habeas corpus* para determinar ao Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do DF que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais.

Publique-se.

Brasília, 19 de outubro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7F0-7744-DFE2-27FF e senha 541C-26CA-E816-7A50